刑法08 筆記：正當防衛—前提事實（現在不法侵害）

> 來源：刑法08 課程字幕 00:20:43 ~ 01:07:47

🕮 法條原文速查

> **§23**（正當防衛）
> 對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。

> **§26**（不能未遂）
> 行為不能發生犯罪之結果，又無危險者，減輕或免除其刑。

> **§302**（私行拘禁罪）
> 私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處五年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

> **§315-1**（妨害秘密罪）
> 有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金：
> 一、無故利用**工具或設備**窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。
> → 純肉眼偷窺不該當本罪

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「現在侵害與將來侵害之界線，有何學說？」	①著手標準說 ②有效防衛說（最寬） ③**預備最後階段說**（實務採）
「家暴殺夫案（趁熟睡殺夫），各說能否正當防衛？」	著手標準說✗、預備最後階段說✗、**有效防衛說✓**（此為唯一能算現在侵害者）
「預先設置防衛設備，是否對將來侵害之防衛？」	**否**，無礙於現在侵害認定（看設備**何時起作用**，非何時設置）
「現在侵害與過去侵害之區分標準？」	**行為的終了**（法益侵害結束），非既遂、非完成
「繼續犯（如私行拘禁）既遂後，能否正當防衛？」	**能**，繼續犯既遂≠終了，被害人被放出才終了，終了前都可防衛
「竊盜既遂後追逐中，能否正當防衛？」	**能**，持有改變＝既遂，但持有穩固＝終了，追逐過程中持有未穩固
「不法侵害之不法，是否須具備罪責？」	**不需要**（形式不法＝該當＋違法即可），對無罪責者可防衛但權限受限
「純民事不法可否正當防衛？」	**多數說可以**（法秩序一體性）；少數說不可（刑法侵犯其他法領域）
「純動物攻擊可否正當防衛？」	**不可**（人的行為才有不法）；但動物背後有人為故意過失→可防衛
「不能未遂之侵害，屬正當防衛或誤想防衛？」	不能未遂＝**假侵害**，不是防衛對象；誤認為真→**誤想防衛**

一、正當防衛的基本架構

```
正當防衛（§23）
│
├── 1. 前提事實：現在不法侵害
│     ├── 侵害要具有「現在性」
│     ├── 侵害要具有「不法性」
│     └── 必須是「人」所為的侵害
│
├── 2. 防衛行為：手段適當（不過當）
│
└── 3. 主觀要件：防衛意識
```

基本想法：面對不法侵害，被害人無義務向侵害者低頭 → 不用先躲避、不用先報警 → 有權直接打回去

二、現在侵害的認定

反面剔除法

將來侵害　→　現在侵害　→　過去侵害
　　↑　　↑
　綠線（三說）　紅線（行為終了）

不是將來、不是過去 ＝ 現在侵害

（一）將來 vs 現在的界線：三種學說

學說	標準	寬鬆度	備註
著手標準說	侵害者行為已達未遂犯的著手階段	最嚴格	預備階段不可防衛
有效防衛說	錯過此時點，防衛將變困難或不切實際	**最寬鬆**	完全不問時空密接性
預備最後階段說	侵害者準備到「下一步就要動手」的最後一步	中間	**實務採此說**
具體危險說	遲延防衛會讓防衛不成功或承擔更大風險	接近有效防衛說	徐志人老師個人見解，少數說

案例演練

案例一：平底鍋案

> 家暴父親在家中找人（找到就要打孩子），大兒子先下手為強，用平底鍋重擊爸爸後腦勺。

學說	結論	理由
著手標準說	✗ 非現在侵害	爸爸還在找人，未著手
有效防衛說	✓ 現在侵害	等找到就被打了
預備最後階段說	✓ 現在侵害	找人是動手前最後一步

案例二：家暴殺夫案

> 嬌小妻子（150cm/40kg）長期遭受館長體型丈夫家暴，趁丈夫喝醉熟睡時持刀刺殺。

學說	結論	理由
著手標準說	✗	丈夫在睡覺
有效防衛說	✓	丈夫醒來後妻子毫無勝算，熟睡時是唯一有效時點
預備最後階段說	✗	丈夫仍在睡覺，不算最後準備階段

> ⚠ 歷久不衰考點，近年仍有轉學考出題

案例三：KTV持槍案（101年國考經典題）

> 持槍歹徒進入KTV在走廊找包廂，服務生先發制人將歹徒打倒。

學說	結論	理由
著手標準說	✗	還在找包廂，未著手
有效防衛說	✓	找到包廂就開槍了
預備最後階段說	✓	找包廂是動手前最後一步

（二）預先設置防衛設備

- **結論**：無礙於現在侵害的認定（**無爭議**）
- **理由**：不看設備何時設置，**看設備何時起作用**
- 例：圍牆通電蛇籠20年前設置 → 小偷來爬牆時起作用 → 至少已著手入侵住宅
- ⚠ 僅現在性過得了，防衛手段是否過當要另行判斷（家用電OK，高壓電過當）

（三）現在 vs 過去的界線：行為的終了

概念	定義	區分意義
既遂	構成要件實現	大多數狀態犯：既遂＝終了
終了	**法益侵害的結束**	正當防衛的最後時點
完成	行為人主觀計畫完成	≠ 終了（相續共同正犯的認定會用到）

```
既遂 ≠ 終了 的犯罪類型
│
├── 繼續犯（如 §302 私行拘禁）
│     ├── 既遂：鎖進倉庫的瞬間
│     └── 終了：被放出來的時候
│     → 既遂後、終了前仍可正當防衛
│
└── 財產犯罪（如竊盜）
      ├── 既遂：持有關係改變（手機拿到手上）
      └── 終了：持有穩固（跳上計程車離開）
      → 追逐過程中持有未穩固，仍可正當防衛
```

三、不法侵害的認定

（一）形式不法：該當＋違法即可

- 通說：**不需要罪責**（法條寫「不法侵害」，非「犯罪行為」）
- 對無罪責者（如精神病患）：**可以防衛，但防衛權受限**（社會倫理限制）

（二）純民事不法

立場	結論	理由
多數說	**可以**正當防衛	**法秩序一體性**：民法可防衛（§149），刑法不讓防衛會矛盾
少數說	不可以	刑法侵犯其他法領域：刑事庭須偷偷判斷民事侵權是否成立

常見純民事不法案例：

- 用肉眼偷窺（§315-1 要求「工具或設備」）
- 使用竊盜（偷騎別人腳踏車）
- 在耳邊低聲罵人（未達公然侮辱）

（三）人的行為才有不法

```
攻擊來源
├── 純動物攻擊 / 自然力 → 無不法 → ✗ 不可正當防衛（可論緊急避難）
└── 動物背後有人為故意過失
      ├── 故意放狗咬人 → ✓ 可正當防衛
      └── 過失未繫狗鍊致狗咬人 → ✓ 可正當防衛
```

（四）假侵害（不能未遂）

- 侵害行為根本**自始不存在威脅性** → 假侵害 → **不是正當防衛的對象**
- 若誤認假侵害為真 → **誤想防衛**（容許構成要件錯誤）
- 案例：拿水槍討債（109年調工組考題），被害人太太誤以為是真槍而捅死對方 → 誤想防衛

（五）純國家社會法益犯罪

- **不可正當防衛**
- 理由（林山田）：維護國家社會秩序是**警察的任務**，一般平民不應自行執法
- 例：看到有人公然猥褻、擺攤賣違禁品 → 報警即可，不可動手

（六）為第三人防衛（緊急救助）

- 正當防衛**可以為第三人為之**
- 最低限度：**第三人不能明確反對**
- 例：看到屁孩欺負流浪漢 → 可為流浪漢防衛 → 但若流浪漢說「不要管我」→ 防衛權消滅
- 學術名詞：**緊急救助**（周揚儀老師用語）

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§23	正當防衛	本筆記核心
§26	不能未遂	假侵害的認定
§302	私行拘禁罪	繼續犯既遂≠終了案例
§315-1	妨害秘密（須用工具設備）	純民事不法案例
民法§149	民法上正當防衛	法秩序一體性論證